

Barber & Fleming, Constitutional Interpretation: The Basic Questions (2007)

Chapter1 The Presuppositions of Constitutional Interpretation

胡韋瀚***

導讀

p/3-5 作者藉由兩個例子(最高法院法官以及美國的律師、法官、政治人物和普通公民的行為)，間接指出了憲法「可能」本身具有意義。然而這種「預設(presupposition)」會引發出 5 個有待探究的「基本問題(basic questions)」。

p/3-4 無論是在法學院或博雅教育學程 (Liberal arts programs)，憲法課程的主要內容並非「憲法本身可能意味著什麼」，或「憲法可能直接對美國人民說了些什麼」。課程內容常常是關於最高法院在超過兩個世紀以來的判決中，曾對憲法所為的各種不同且相互競爭的解釋。因此，多數的憲法課在某種程度上是種「關於最高法院曾對憲法說過什麼」的歷史課程。

關注於法院及其歷史當然不需要什麼辯解，蓋其對於美國人的生活有著顯而易見的影響。況且，對於法院如何成為現狀的認識，往往是法院下一步可能走向何方的一個相當好的指標。

P/4-5 但是，憲法肯定還有更多最高法院曾解釋過或將來可能解釋以外的意義存在。這種「還有更多」的想法，被一種頑固的感受或直覺所指明：最高法院曾說過甚麼的歷史，僅是一種「對於『僅能透過正式修憲才能變更的』憲法文件所為的不同詮釋」的發展。美國人民普遍地擁有被以下兩個熟悉且相關的國民經驗所指明的感受或直覺：最高法院的法官普遍地宣稱：

1. 無論他們的解釋多麼具有爭議性，這些解釋皆係忠於憲法本身。
2. 那些不同意他們的人是錯誤的——亦即，對憲法有所誤解。

這些相關的宣稱「預設」了憲法的含意並不仰賴於任何人對於憲法特別的解釋。換句話說，「忠實性(fidelity)」以及「錯誤可能性(fallibility)」的宣

* 東吳大學 114 學年度第 2 學期；憲法專題研究（四）；授課老師：湯德宗 教授；導讀日期：2026 年 3 月 16 日。

** 東吳大學公法組碩士班三年級

稱，預設了憲法本身有其意義存在。

p/5 憲法本身是否能具有任何意義，是哲學家、政治學家、法律學者和法學家之間存在重大分歧的問題。本書的兩位作者都沒有為自己找到一個理智上確定的答案，並且，兩位作者目前都傾向於不同的答案。

然而作者在此的主要目標是描述性與分析性的。在描述層面上，作者注意到無人能成功否認：美國的律師、法官、政治人物和普通公民，通常在談論憲法與法院時，表現得好像法院「可能搞錯」憲法一樣；而在這樣做的同時，他們便預設了憲法擁有獨立於法院或其他詮釋者所言之外的意義。

作者相信，無論這種特定的預設最終是否站得住腳，它都是持有政治觀點的美國人的政治意識中無可避免的一部分。在本書中，作者將探討由「憲法本身具有意義」這一預設所引發的基本問題。這些基本問題關乎：

1. 憲法的字句（如「平等保護」和「通商」）所指為何？
2. 憲法作為一個整體是什麼樣的事物？（是一份契約？一套具體的歷史規則法典？還是一部抽象道德原則的憲章？）
3. 取得憲法意義最站得住腳的方法為何？（或者，應如何詮釋憲法？）
4. 誰（如果有的話）對於憲法意義可能擁有最終決定權（或者，誰可以權威地詮釋憲法？）
5. 憲法詮釋的極限，例如與制定法律或修憲間的區分。

p/5-6 就前述基本問題，作者亦稱之為「解釋性問題(interpretive questions)」或「原則性問題(principle questions, p/12)」以與憲法實體問題(substantive question)為區分。

p.6 實體問題的答案旨在告訴我們，例如：死刑是否在某些情況下或總是屬於殘酷行為，從而違反了第八修正案對「殘酷且異常的處罰(cruel and unusual punishments)」的禁止；決定墮胎或進入同性關係的權利，是否受到第五和第十四修正案「正當法律程序條款(Due Process Clauses)」中自由保障的保護；或者美國童軍（一個「私人」組織）是否擁有排除同性戀者和無神論者的憲法權利。

而作者所稱的解釋性問題，其答案旨在告訴我們：(What)憲法是什麼以及其字句所指為何；(How)如何以最佳方式探求憲法的意義；以及(Who)誰（如果有的話）對該意義擁有最終決定權。

憲法意義的實體議題是憲法的「底線性（Bottom-line）」問題；它們是律師和普通公民最先感興趣的事物。解釋性議題雖然本身就很有趣，但對大多數人而言，通常只有在意識到解釋性問題對那些底線問題的影響之後，才會變得具有吸引力。

p/6-7 作者藉由最高法院的幾個困難案件來說明解釋性問題的意義、重要性以及為何實體問題乃「底線性問題」。

- **McCulloch v. Maryland (1819)**：本案法律爭點在於，國會可否推翻州政府的反對意見並在州內設立國家銀行的分行。這個實體問題轉變為「憲法是甚麼？（一個抽象地憲章（a general charter）還是一個詳盡的法典（a detailed code）？）」以及是否要廣義地或狹義地去解釋憲法第1條第8項賦予國會的權力。
- **Dred Scott v. Sandford (1857)**：本案法律爭點在於，一位非裔美國人可否要求聯邦法院判決其是否被合法地宣稱為一位奴隸。這個實體問題轉變為「在憲法解釋中，制憲者的意圖扮演著甚麼角色」、「如何找到制憲者的意圖為何」以及「是否具體地或抽象地理解有關意圖」。
- **Lawrence v. Texas (2003)**：本案法律爭點在於，一個州政府可否將合意且成年的同性親密性行為加以入罪。問題的解答涉及諸多解釋性的問題如，第十四修正案中「自由（liberty）」的意義，是否由對於「自由的本質」的合理判斷來決定。或者相對地，是否由州法自1868年—第14修正案制定時，在「傳統」或「歷史」上對於自由的認識來決定。
 - 反對者希望將近期美國和歐洲法律中有利於同性戀權利的趨勢排除在「傳統」的概念之外。
 - 多數意見則主張將這些「近期傳統」納入其中。

這使得讀者不禁詢問：「傳統」的本質和規範效力究竟存在於「具體的歷史實踐」，還是「抽象的道德原則」？

- ***DeShaney v. Winnebago County Department of Social Services (1989)***：
本案的法律爭點在於，是否一個旨在保護孩童免受虐待而設立的州部門，具有憲法上的義務去保障孩童免受暴力父母完全可預見的侵害。問題的答案涉及對於憲法做為一個整體的為何的不同觀點：
 - 多數意見認為憲法式設計來保障人民免受政府的侵害，而非保障人民免受其他私人的侵害。
 - 反對意見則認為國家有義務去保障孩童，因為孩童無法保障自身；並且因為州兒童福利制度的存在，使得威斯康辛州民(Wisconsinites)對州政府實際保護受虐兒童的程度產生了自滿情緒。
- ***Brown v. Board of Education (1954)***：本案法律爭點在於，第十四修正案之平等保障條款是否允許州政府在公立學校實行種族隔離。本案最終轉變為憲法的意義是否受到過去在明顯不同的社會環境下所做成的憲法解釋所拘束。

p/7-10 作者對於那些主張「法官做成判決，並非基於其對於『憲法本質』或『獲得憲法意涵的最佳方法』這種抽象哲學問題的答案，而是基於其個人的政治偏好」以及「即使法官慣常地使用廣義的『司法哲學』和『憲法原則』等用語來合理化其判斷，但這種合理化事實上只是在為基於個人政治立場而做成的決定，所進行的事後粉飾（Window dressing）而已」的見解指出其矛盾之處。

1. 作者同意在某些案件中，法官確實可能會受其自身政治偏好所影響，但絕非「總是如此」，並提出以下三點反駁：
 - (1) 如果法官就是無法克服其自我證成的黨派偏好的話，那麼對於那些對法官抱持著憤世嫉俗看法的學術作家來說，類似的情況也必然是真的。
 - (2) 如果法官出於某種原因，無法真誠地關心說理與證據所顯示的「憲法本質」（它是什麼樣的事物）以及「憲法意義」（如何詮釋它以及其字句間的含義），那麼就很難看出，學者們又如何能誠實地關心理論辯證與證據衡平所顯示的「司法裁判之本質」。
 - (3) 如果法官必須以自利（self-serving）的方式判斷爭議性法律問題的話，那麼科學家與學者在回答具爭議的科學問題時，難道就能不以自利的方式來回答嗎？
2. 司法裁判必然是自利（Self-serving）的，這是一個具爭議性的主張，因為法官通常會否認這一點。通常情況下，無論他們的裁判多麼具有爭議，他

們都會聲稱自己忠於法律。

- (1) 因此，若說「司法裁判必然是自利的」，其實在暗示說：「儘管法官否認，但司法裁判必然是自利的，這是一個事實。」這實際上是在以一種「隱含地聲稱自己是出於對事實真相的關切」（而非出於某種自利的回應）來回答一個具爭議性的科學問題。
- (2) 如果科學家能夠出於對真理或「最佳解釋」的關切，來處理有關司法行為的爭議性議題，那麼為什麼法官不能出於對真理或「最佳詮釋」的關切，來回答具爭議的憲法問題呢？難道與那些被自然科學或社會科學吸引的人相比，那些被法律與法律學術生涯吸引的人，在人格上特別有缺陷嗎？我們並未發現任何支持這一點的科學證據——沒有證據顯示，那些職業上關注憲法問題的人在天性上是不誠實的。
3. 或許，關於憲法意義的問題確實有其獨特之處：你可能會說，與科學問題不同，憲法問題的答案（關於憲法是什麼以及它意味著什麼）具有即時的政治影響，這在情感上吸引或排斥著我們。
 - (1) 以 DeShaney 案為例。六位大法官可能認為憲法並未規定政府有義務幫助一個無助的孩子，是因為他們對「福利國家」持有保留意見，並且因為他們擔心，一旦要求政府有義務保護兒童免受可預見的暴力，他們將無法在該義務與要求政府保護兒童免受飢餓、無知以及缺乏有意義的經濟、社會與政治機會之間，劃出一條界限。
 - (2) 因為憲法問題通常帶有這類的政治影響，牽動著我們的情緒；故有人可能會主張，我們的情緒阻礙了追求真理所需的那種超然且自我批判精神的努力——即便在那裡可能存在著客觀真理或最佳詮釋可供追求。
 - (3) 對此，作者認為：科學問題所具有的即時政治與情感影響，並不亞於憲法問題。考慮以下這些公認的科學問題如「宇宙起源」、「物種起源」、「是否有些人天生即為同性戀」、「全球暖化的成因」，以及「對憲法原則真誠且具自我批判精神的關切能在多大程度上影響憲法案件的判決」即可知。試舉一例：如果吾人相信科學證據指出，性傾向大多是受遺傳基因所影響，那吾人可能就會認為，對於同性戀者的歧視，是錯誤的。
 - (4) 這些特定例子中的科學問題並沒有什麼獨特之處。一個公認的科學問題是否事實上具有即時的政治影響，完全是一個環境問題。畢竟，我們現在所稱的太陽系是「日心說」還是「地心說」，在歷史上的某個時點也曾

是具有政治後果的問題。在 1940 與 50 年代，孟德爾遺傳學在史達林統治下的俄國也是不受官方待見的。

- (5) 如果沒有人能確認任何具有政治影響之主張的真偽，那麼也就沒有人能說「（事實上）憲法問題的答案只不過是在為個人偏好進行合理化」，因為這個主張本身就具有明確的政治影響：即美國司法權的正當性。

（※有政治影響→所以即使存在也無法追求真理→批判者主張「憲法問題的答案只不過是在為個人偏好進行合理化」→這個批判也具有政治影響→那這個主張也同樣不具超然且自我批判的追求真理的精神→主張不成立）

p/10-11 對於「憲法具有真實意義」以及「最佳詮釋」的可能性，為何應保持開放態度的說明

無論法官是否能真誠地探求憲法的真實意義，或者憲法是否真有一個值得探求的真實含義，無人懷疑法官通常「聲稱」自己關心憲法的真實含義；因此，司法的修辭預設了「真實的憲法意義」或「最佳詮釋」的可能性。

這種可能性基於以下兩點理由，應保持開放性：

1. 正如我們剛看到的，要否定這種可能性是很困難的。沒有任何理由在否定「憲法真理」或其「真誠探求」之可能性的同時，卻不同時否定「科學真理」及其「誠實探求」之可能性。
2. 即使憲法原則僅僅是被用來合理化基於其他理由所做成的判斷，這些原則仍會在某種程度上拘束憲法判斷。我們可以想像許多政府行為，是很難用憲法術語來合理化的。例如：直接且公開地使用稅金以在全國學齡人口中培養基督教的世界觀；認真地企圖執行將「婚前性行為」或「避孕」刑事化的法律等。

這些例子當然是假設性的，但這並不代表它們不切實際。它們與當今美國具影響力團體的政治野心、原則或行為是一致的。而這些行為顯然違憲的事實，顯示了憲法具有約束政治選擇的某種力量。

p/11-12 當談到詮釋者尋找憲法的真實含意或最佳解釋時，可能會使人以為作者預設了一個道德現實(moral reality)的存在，卻未提供一個有說服力的方法以探究該道德現實如何構成。作者對此有所回應

1. 作者並未主張於此存在著一個道德現實。相對地，作者主張詮釋憲法的志業僅僅只是預設了一位認真且負責的詮釋者在追尋著憲法的真實含意以及最詮釋。這種預設並未包含宣稱在憲法素材中存在一個真實的含意，更不用說保證一定存在一個。簡單來說，作者僅僅只是在說明憲法解釋的「前提」，而並非對於道德現實做一個本體論(ontological)的宣稱。
2. 兩位作者在道德現實主義(moral realism)與建構主義(constructivism)間本體論的爭論尚有歧見，簡單來說，在「認為憲法詮釋是在尋求體現在憲法中的真實概念之真實含義」以及「在尋求對我們的憲法實踐、傳統與承諾的最佳詮釋」間的歧見。基於此理，在寫作本書時，作者對此先採取一種不可知論(agnostic)的態度。